

1501120-52.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... a condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na vigência da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76, artigo 12). Aduziu-se que, na espécie, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas ficara devidamente comprovada nos autos e que não fora afastada pela defesa na apelação e nas demais impetrações posteriores. Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501120-52.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501120-52.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2344912/2021 - Delegacia de Polícia de Roseira, 22032964 - Delegacia de Polícia de Roseira, 2476/21/201 - Delegacia de Polícia de Roseira, 2344912 - DEL.POL.ROSEIRA, 2476/21/201 - DEL.POL.ROSEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAFAEL DA SILVA HONORIO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública contra RAFAEL DA SILVA HONÓRIO, devidamente qualificado nos autos, apontando-o como transgressor do disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 14h30min, em frente à residência localizada na Rua José Benedito Machado, nº 32, bairro Jardim Primavera, nesta cidade, o acusado mantinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 09 microtubos tipo eppendorf contendo "cocaína", pesando aproximadamente 03g, e 07 frascos contendo cloreto de metileno/dicloreto de metano, substância vulgarmente conhecida como "lança-perfume" ou "loló", substâncias capazes de causar dependência física e

psíquica, conforme laudo de exame químico-toxicológico. Conforme a narrativa extraída da acusação, o acusado, que se dedica à venda de entorpecentes, posicionou-se nas imediações de uma praça situada no bairro acima mencionado, local frequentado por usuários de drogas, aguardando a chegada de compradores, escondendo as drogas em um terreno baldio. Em razão de denúncia anônimas recebidas, a Polícia Militar deslocou-se para o local, oportunidade em que flagraram o acusado negociando a venda de drogas com outra pessoa, oportunidade em que fora abordado. Em busca pessoal lograram localizar R\$ 20,00, em dinheiro, e um aparelho celular. Na sequência, em buscas promovidas no terreno baldio encontraram uma sacola plástica, que continha os entorpecentes apreendidos. Por fim, o titular da ação penal pretende a perda em favor da União do dinheiro e do aparelho celular.

Em cumprimento ao disposto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06 o acusado foi notificado e não apresentou a defesa preliminar no prazo legal.

Denúncia ministerial acolhida pela decisão de fls. 144, que também examinou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.

Houve a apresentação tardia de defesa à fls. 150, arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Durante a fase de instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 200 a 202). O réu foi interrogado à fls. 203, negando a propriedade da droga apreendida.

Em sua derradeira manifestação o Ministério Público propôs a condenação do acusado, apoiando-se no acervo probatório compilado pela instrução criminal. Sustentou que os depoimentos dos policiais deram conta da autoria do delito de tráfico por parte do agente, somados ao encontro da droga, em quantidade considerável, em local frequentado por usuários. Também menciona a negociação da venda pelo acusado, reforçando a certeza da mercancia. No que se refere à pena, buscou sua exasperação em face da reincidência do acusado, com aplicação do regime mais severo para se desconto, ponderando pela impossibilidade de aplicação da causa especial de redução de pena do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em decorrência da recidiva. Requereu, por fim, a perda do dinheiro apreendido em favor da União (fls. 213).

Em sentido oposto veio a pretensão da defesa do acusado, sustentando a absoluta ausência de provas a respeito da vinculação do réu com os produtos apreendidos pela ação policial, isto em razão da existência apenas de testemunhos de policiais. Aposta na fragilidade das provas ao argumento de que os entorpecentes não foram apreendidos em poder do agente, mas em terreno baldio, acessível a qualquer pessoa. Destacou o policial FABIANO alegou que não era possível visualizar aquilo que o réu tinha em suas mãos, não se desincumbindo a acusação do ônus de provas a vinculação do réu com os entorpecentes, ponderando que o acusado não registra passagem anterior pela polícia local. Em caso do procedência da ação penal busca a fixação da pena em seu patamar mínimo, com aplicação do regime da semiliberdade, pois o réu não é reincidente específico (fls. 232).

É o breve apanhado do processo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito é certa. Submetida a substância em questão ao denominado Exame Químico Toxicológico (fls. 197), constatou-se que, de fato, cuidava-se de cocaína e de "cloreto de metileno/dicloreto metano, substância vulgarmente conhecida como "lança-perfume" ou "loló", comprovando, assim, seu atributo psicotrópico, capaz de causar dependência psíquica, incluída, portanto, incluída, portanto, na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98, republicada no Diário Oficial da União de 01/02/99 e a RDC nº 18,

da Agência de Vigilância Sanitária, datada de 28/01/03.

Em reforço ainda há o Boletim de Ocorrência de fls. 15, o auto de exibição e apreensão de fls. 18, bem como o laudo de constatação provisória de fls. 24.

Da mesma maneira a autoria do crime em questão desponta da prova angariada de forma robusta e coesa, ainda que o acusado tenha negado sua vinculação com os produtos entorpecentes apreendidos na ação policial - fls. 203.

A prova testemunhal colhida sob o manto do contraditório também é inegavelmente contrária à postulada absolvição.

Os policiais militares FABIANO AUGUSTO COELHO SANTOS e SANDRO SILVA PINTO (fls. 200 e 201) relataram de modo detalhado a ação ocorrida, destacando que tinham informações anteriores de que no local três agentes praticavam o tráfico. Assim, passaram a monitorar o local à distância, podendo visualizar o exato momento em que uma terceira pessoa fez contato com o acusado, entregando-lhe algo, momento em que este se deslocou até um terreno baldio, abaixou-se e colocou um objeto de cor branca próximo a um arbusto. Em seguida, o réu conversou com a outra pessoa que por sua vez se dirigiu até uma adega, retornando com uma garrafa de refrigerante na mão. Nesse instante, realizaram a abordagem dos agentes, que foram revistados, encontrando em poder do acusado a quantia de R\$ 20,00, em dinheiro. Entrevistados, o comprador admitiu que havia comprado "maconha" por R\$ 10,00, entregando ao réu uma nota de R\$ 50,00, contudo, ele lhe falou que naquele momento não possuía a droga que o usuário pretendia adquirir, solicitando que aguardasse alguns instantes pela chegada de um comparsa que traria o entorpecente. Rumaram com o acusado até o terreno, onde apreenderam os entorpecentes. No início, o réu negou a atividade criminosa, mas depois acabou admitindo a autoria do crime. Disseram, por fim, que próximo ao local dos fatos há uma escola.

O Policial Civil SILVÉRIO LÚCIO DUARTE PACHECO, ouvido à fls. 202, relatou que estava de plantão no dia da prisão do acusado e acompanhou todos os procedimentos. Contou que observou uma excessiva preocupação do réu com a apreensão de seu celular. Acrescentou que tinha informações de que indivíduos de Pindamonhangaba teriam se mudado para a cidade de Roseira e estariam realizando tráfico no local, inclusive com a "compra de biqueiras" dos bairros, escondendo as drogas nos matos próximos à linha férrea, sendo o réu apontado como um desses traficantes.

A prova edificada pela acusação, portanto, é tenaz e não foi minimamente mitigada pela combativa defesa, nem mesmo para propiciar uma possível desclassificação, isto não apenas em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas sobretudo em decorrência da dinâmica dos fatos, que contou com a presença de um usuário que se aproximou do acusado para a compra dos entorpecentes, conforme reportados pelos milicianos.

Nítida, por conseguinte, a mercancia praticada pelo acusado no dia dos fatos, mais do que suficiente para o reconhecimento da pretensão punitiva ministerial.

Também muito estranha a postura do acusado na fase policial, em que permaneceu em silêncio diante de tão grave acusação. Muito embora o direito ao silêncio seja garantido aos acusados, inclusive imperativo constitucional, essa postura me parece incompatível com quem é inocente e se vê acusado de algum crime. É natural, em tais circunstâncias, que a pessoa acusada se defenda, ainda que simplesmente negando os fatos.

"Embora constitucionalmente garantida a possibilidade de o acusado permanecer em silêncio na fase extrajudicial, não se pode ter como plausível que alguém inocente admita ser injustamente apontado como autor do delito e não manifeste nenhuma oposição, sendo certo que, mesmo que o silêncio não deva ou não possa ser

interpretado em desfavor do acusado, não é lógico ou normal do ser humano a passividade diante de uma infundada acusação, máxime se inexistem sinais de que tenha sido compelido a se calar naquele procedimento investigatório, uma vez que, a só quietude do réu não basta para fundamentar um decreto condenatório, mas pode servir como parâmetro para um convencimento judicial desfavorável" (TACrimSP - Ap. nº 1.305.945/2 - Lençóis Paulista - 11ª Câmara - Rel. Pires de Araújo - 24.6.2002 - v.u).

"PROVA - Interrogatório judicial - Silêncio do réu - Eficácia: - Inteligência: artigo 61, I do Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, IV do Código Penal. O silêncio do réu, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, é atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo assim a oportunidade de esclarecer, de pronto, algum equívoco de seus acusadores" (TACrimSP - Ap. nº 1.129.029/8 - 15ª Câmara - Rel. Fernando Matallo - J. 14.01.99 - RJTACRIM 43/228).

Não resta a menor dúvida de que as drogas apreendidas naquela oportunidade pertenciam ao acusado e eram destinadas ao tráfico, inversamente do que tentou fazer crer a combativa defesa. A quantidade apreendida não é nada desprezível (09 microtubos tipo eppendorf contendo "cocaína", pesando aproximadamente 03g, e 07 frascos contendo cloreto de metileno/dicloreto de metano), que certamente não eram para o uso pessoal do réu, que jamais admitiu qualquer vinculação com os entorpecentes, certamente por ter conhecimento de que o reconhecimento da mercancia seria inevitável.

O ônus da prova, segundo regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe a quem o alega, no caso específico ao imputado, pois flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como localizado entorpecente em local em que havia sido visto pelos policiais.

"Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive da paridade de tratamento das partes" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado - pg. 220).

"Quem invoca um alibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (Ap. 53.726 - TACRIMSP).

"Iterativa a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, sob pena de ser tido como réu confesso" (Rev. 37.688 - TACRIMSP).

Não há como não acreditar na versão da polícia, inclusive de que o réu confessara informalmente. Ressalte-se que os homens da força pública são agentes credenciados pelo Estado e como tal merecem confiança especial em seus relatos, ainda mais se coerente com a prova amealhada em juízo. De resto, a defesa não conseguiu comprovar qual a razão de eventual comportamento indigno do policial.

Afora isso, não é possível que se alegue que os testemunhos apenas de policiais não são válidos para servir de lastro a embasar o decreto condenatório, tema já exaustivamente debatido nos tribunais, cuja conclusão majoritária é no sentido de seu total acolhimento, ainda mais se amparado em outras provas colhidas, conforme sucede na espécie.

A idoneidade dos agentes da polícia, como já frisado, é presumida e somente pode ser vencida através de prova plena e inequívoca, esta ausente na hipótese "sub judice".

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseveraram que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição” (RT 614/275).

Não existe qualquer contradição digna de nota nos testemunhos dos policiais.

Significante também é a quantidade da substância apreendida e que não pode ser singelamente ignorada, na medida em que um frasco poderia servir a várias pessoas – ao todo foram localizados 07 frascos.

“Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, relevante é a verificação da quantidade da substância proibida apreendida, a fim de se cotejar esse elemento com outras circunstâncias que envolvem a prática da infração, máxime quando se pretende provar que alguém é mero usuário e não traficante” (JUTACRIM 54/315).

“Tóxicos - Traficância - 7,24 g de cocaína e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente, 144, 145 “carreirinhas”.... (RJ TJRS 159/192).

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papérolas de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal n. 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

“Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no art. 12 da Lei nº 6.368/76” (RJ TJRS 145/115).

A prova, ao contrário do que advoga a combativa defesa, não é nada frágil. Ao contrário, reveste-se de elementos seguros a confirmar a narrativa constante da peça acusatória, deixando claro que o acusado realmente estava no local para comercializar a cocaína e os lança-perfumes apreendidos durante a bem-sucedida ação policial.

Da mesma forma merece prestígio a pretensão ministerial que reclama o perdimento do dinheiro apreendido, cuja origem não foi comprovada pelo acusado. Ao contrário, a prova revela que se tratava de renda auferida com a narcotraficância que grassava no local.

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Apreensão de toneladas de acetona e éter sulfúrico destinados ao refino de cocaína - Natureza associativa da atividade dos acusados, em vasta rede nacional e ao que indica, internacional, ademais comprovada - Condenação de rigor com fixação da pena e decretação da perda dos bens apreendidos conforme o art. 34 da Lei Antitóxicos” (Relator: Dirceu de Mello - Apelação Criminal 91.096-3 - São Paulo - 11.09.91).

“ENTORPECENTE - Tráfico - Perda do veículo utilizado no transporte da droga -

Admissibilidade - Controvérsia quanto à propriedade do bem - Discussão afeta ao Juízo Cível - Inteligência do art. 120, § 4º, do CPP" (TRF - 3ª Reg. RT 741/725).

Assim sendo, transitada em julgado a sentença, remetam-se ao Senad relação dos valores declarados perdidos em favor da União, conforme artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A mesma sina não deve ser dada ao aparelho de telefonia celular. A prova pericial levada a efeito não foi capaz de concluir que o acusado fazia uso do aparelho para a atividade criminosa. Há dúvidas quanto a isso, eis que o exame pericial não foi capaz de acessar o conteúdo das mensagens armazenadas no aparelho, ainda que a polícia tenha percebido uma preocupação anormal do réu com a apreensão desse aparelho - fls. 171.

Concluindo sem sobra de dúvidas de que o réu merece a censura penal, passo agora a dosimetria da pena a ser imposta, observado o sistema trifásico previsto pela legislação penal - artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. A condenação anterior, registrada pela certidão de fls. 53, será objeto de apreciação como agravante genérica, sob pena de "bis in idem". A quantidade de drogas apreendida, embora não possa ser rotulada de modesta, também não autoriza o aumento previsto pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena-base do acusado em cinco (05) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes. O réu, entretanto, é reincidente, já tendo sido condenado com sentença passada em julgado por crimes graves [roubo qualificado e corrupção de menores - processo nº 0003066-87.2017.8.26.0520], conforme certidão de fls. 53. A reincidência é agravante genérica, na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal, o que implica na exasperação da pena-base, no caso de 1/6, no mínimo por se tratar de apenas uma recidiva, totalizando cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 traz causa especial de redução de pena ao dispor que nos delitos definidos no "caput" e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A despeito das circunstâncias judiciais serem favoráveis, a prova descortinada revela que o acusado é reincidente, portanto, não é mais primário. Além disso, dedica-se a atividades criminosas, pois em momento algum ao longo da tramitação do processo fez prova de exercício de ocupação lícita.

Acrescente-se que para se beneficiar da causa especial de redução de pena o réu não deve integrar organização criminosa. O delito de tráfico é uma grande engrenagem com inúmeras peças. Vai desde o fabrico da substância entorpecente até o destinatário final que são os consumidores. Até que isso ocorra inúmeras pessoas são envolvidas nessa cadeia criminosa, o que comprova que a apreensão de quantidade razoável de lança-perfume decorre de organização criminosa que tem toda uma logística, com recrutamento de várias pessoas que atuam em diferentes áreas, no caso do acusado a venda de pequena quantidade. Não existe dúvida alguma de que o réu faz parte desse importante braço da organização, cujo objetivo é a venda dos entorpecentes a usuários da região, contribuindo, inegavelmente, para aumentar o público desse lucrativo negócio. Irrelevante o fato de o acusado não conhecer os demais integrantes dessa organização, pois também faz parte do sucesso desse tipo de empreitada criminosa a separação entre os diversos componentes da organização. O acusado sabe muito bem que para que a droga chegue até ele tem que passar por outros integrantes da organização. Por conta disso tudo, não merece a redução da pena.

"HABEAS CORPUS - Penal - Tráfico transnacional de drogas - Dosimetria da pena devidamente fundamentada - Aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Réu integrante de organização criminosa - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito - Ausência de requisito objetivo - Ordem denegada. O indeferimento da causa especial de redução do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse. Ordem denegada" (STF - HC nº 111.398 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 17.04.2012 - DJE 03.05.2012).

"Para que a redução da pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Com base nesse entendimento, a Turma desproveu recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a incidência da referida causa especial de diminuição de pena a condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na vigência da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76, artigo 12). Aduziu-se que, na espécie, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas ficara devidamente comprovada nos autos e que não fora afastada pela defesa na apelação e nas demais impetrações posteriores. Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto também denegaram o recurso, mas por fundamento diverso, consentâneo com a óptica do tribunal estadual, no sentido de que o aludido parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica à situação concreta regida pela Lei 6.368/76, sob pena de se olvidar o critério unitário, chegando ao conglobamento com o surgimento de uma nova regra normativa" (STF - RHC nº 94.802 - RS - Rel. Min. Menezes Direito - J. 10.02.2009).

"TÓXICOS - Tráfico - Afastamento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Cabimento - Condenados encontrados em atividade criminosa - Quantidade de drogas indicativa de relacionamento estreito dos réus com o crime organizado - Recursos dos réus desprovidos e recurso ministerial provido" (TJSP - Ap. nº 990.10.045.033-6 - Botucatu - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Orestes de Souza Nery - J. 05.08.2010 - v.u.).

"PENA - Redução - Prática de tráfico de entorpecentes - Aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora o réu seja primário e não registre maus antecedentes, mostrou comportamento voltado ao delito, não sendo recomendável a adoção dessa medida, que, aliás, é de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que "as penas poderão ser reduzidas", ficando ao prudente arbítrio do Julgador essa análise no caso concreto - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 1.156.870-3/6 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 13.3.2008 - V.U.- Voto n. 7.100).

Não sendo encontradas outras causas, especiais ou gerais, de aumento ou diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

A multa prevista de forma cumulativa deve ser fixada dentro dos mesmos critérios para o encontro da pena-base, inclusive com o acréscimo resultante da recidiva. No tocante ao valor, deve-se ter em mira o conteúdo do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/06, no caso no mínimo legal frente à situação econômica nada privilegiada do réu, atualmente privado de sua liberdade.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei nº 11.464/07. O crime de tráfico, além de ser equiparado aos delitos hediondos, é sempre grave, justamente porque atinge a saúde pública. Além do mais, fomenta uma série de outros delitos graves, inclusive o tráfico de armas e os crimes patrimoniais violentos,

amiúde cometidos por usuários. Por conta disso, a resposta à sociedade por parte do Poder Judiciário deve ser austera, sob pena não se criarem mecanismos de inibição ao cometimento desse grave delito. Lembre-se que o réu é reincidente e estava descontando pena em regime aberto, segundo a certidão de fls. 53, de sorte que o citado regime e nem o tempo de segregação anterior o inibiram de tornar a delinquir, de modo que não é possível correr novamente esse risco.

“PENA – Regime – Fixação – Tráfico de entorpecentes – Com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime de cumprimento de pena não pode mais ser o integralmente fechado, modalidade assinada somente para a fase inicial de cumprimento – Recurso provido” (Apelação Criminal nº 1.039.230-3/2 – Catanduva – 8ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal – Relator: Lourival Barbiero – 11.9.07 – V.U. – Voto nº 2.439).

“TÓXICOS – Regime prisional – Tráfico – Fixação da modalidade inicial fechada – Necessidade, nos termos da Lei n. 11.464/07 – Regime integral fechado – Descabimento – Recurso parcialmente provido para estabelecer o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade” (Apelação Criminal n. 1.060.484.3/0 – Santos – 9ª Câmara Criminal – Relator: René Nunes – 26.09.07 – V.U. – Voto n. 10.932).

A regra contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não altera o regime carcerário levando-se em consideração o tempo de prisão preventiva do acusado, pois ainda não cumpriu tempo suficiente da pena para obtenção de progressão de regime (artigo 112 e incisos da Lei de Execução Penal). Além disso, o artigo 112, “caput”, e § 1º, da Lei de Execução Penal exigem, além do requisito objetivo para a progressão (tempo de cumprimento da pena), bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, informações estas que não constam dos autos, impedindo, portanto, a fixação do regime menos severo.

“(…) No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei n.º 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena (…)” (TJ/SP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n.º 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. Alberto Mariz de Oliveira, j. em 04.06.2013).

“Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença” (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro: 16/08/2016).

A vedação ao regime mais benéfico, ainda que o intermediário, não resulta apenas

quando se está diante de reincidência específica, não havendo distinção por parte do legislador neste particular.

Pela ausência de pressuposto objetivo (quantidade da pena) e a hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "SURSIS" (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Também não merece ser agraciado com nenhuma das penas alternativas previstas pelo artigo 43 do Código Penal introduzidas pela Lei nº 9.714/98.

Ocorre que a pena aplicada ultrapassa, em muito, o pressuposto objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, inviabilizando por completo a substituição. Por fim, a substituição mostra-se absolutamente incompatível com a gravidade do delito e sua condição de equiparado aos hediondos, não sendo, portanto, socialmente recomendável.

Além disso, esse tipo de substituição deve ser reservada a crimes de pequena gravidade e é incompatível com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, crime de acentuada gravidade e até mesmo equiparado aos hediondos, exigindo por parte do julgador tratamento mais severo, como forma de frear essa atividade, que de tão lucrativa que é a cada dia recruta mais integrantes. Somente com penas severas, efetivamente cumpridas, que esse tipo de delito pode ser contido. Conceder a traficantes a substituição em questão, com a devida vênias dos que pensam diferente, é estimular o tráfico. O argumento de que o julgador deve diferenciar o pequeno do grande traficante mostra-se irrelevante. O tráfico de drogas é mecanismo de grande porte e, como toda engrenagem, depende das pequenas peças para seu perfeito funcionamento. Sem o pequeno traficante não há como difundir o uso das drogas, de sorte que este é fundamental para o sucesso desse mercado clandestino. No mais, comumente quem vicia nossos jovens e vende drogas na porta das escolas e em festas, como no caso dos autos, são os chamados "pequenos traficantes".

"TÓXICO - Tráfico - Pena restritiva de direitos - Lei n. 9.714/98 - Aplicação - Inadmissibilidade - Lei de drogas e de crimes hediondos que não admitem a concessão de benefícios - Vedação, ademais, pelo artigo 44, I, do Código Penal - Recurso não provido" (Apelação Criminal n. 289.157-3 - São Paulo - 1ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Passos - 18.01.2000 - V.U.).

"PENA - Restritiva de direitos - Tráfico de entorpecentes - Substituição da privativa de liberdade - Impossibilidade - Obediência ao artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 9.714/98 - Necessidade - Reconhecimento da especialidade da lei de drogas e da Lei nº 8.072/90 - Hipótese - Recurso improvido" (Apelação nº 934.955-3/4 - Pederneiras - 11ª Câmara Criminal - Relator: Antonio Manssur - 2.8.06 - V.U. - Voto nº 11.274).

"PENA - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto" (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - V.U. - Voto nº 15.940).

Veda-se ao réu o apelo em liberdade. Primeiro porque que aguardou o desfecho da instrução segregado, sendo que agora, depois de condenado, a soltura seria verdadeiro paradoxo. Segundo porque já não é mais primário, de sorte que esse benefício deve ser concedido apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular. A libertação do inculcado serviria de estímulo à criminalidade e não se prestaria a colocar freio na vertiginosa onda de crimes que assola e atemoriza nossa sociedade, principalmente o tráfico de drogas, que tem destruído inúmeras famílias. Além disso, conforme já sublinhado quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, os

pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva estão presentes, havendo efetivo risco para a aplicação da lei penal, notadamente em virtude da condenação e da pena elevada imposta ao agente. As demais medidas cautelares previstas pelo artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal não são suficientes à gravidade do delito e, em especial, à condição pessoal do acusado, conforme exigido pelo artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Observo que o crime imputado ao agente tem pena máxima que ultrapassa a quatro anos de prisão, permitindo, portanto, a custódia cautelar (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). A gravidade do delito é concreta e a libertação do acusado, principalmente nesta fase do processo, com pena aplicada, soaria a todos, inclusive a ele, como impunidade. No mais, ficam reiterados os argumentos empregados por ocasião da r. decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva, pois perfeitamente válidos ao caso, assim como aqueles manejados em decisão que examinou a necessidade da manutenção da medida - fls. 144.

"CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Tráfico de entorpecente - Condenação - Regime inicial fechado - Crime Hediondo - Negado o apelo em liberdade - Legalidade - Não caracterização - Perniciosidade do tráfico que justifica a continuidade da segregação - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 247.004-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal de Férias de Janeiro/98 - Relator: Segurado Braz - 14.01.98 - V.U.).

"HABEAS CORPUS - Réu preso em flagrante e condenado por prática de crime hediondo, tráfico de entorpecentes, que recorreu da sentença e que pretende liberdade provisória para aguardar o resultado do julgamento - Alegação de que necessita de tratamento médico - Irrelevância - Obrigação do Estado de fornecer o aludido tratamento - Artigo 35 da Lei 6.368 de 1976, que manteve a permanência na prisão como condição do apelo - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 259.177-3 - Barretos - 6ª Câmara "JULHO/98" de Direito Público - Relator: Debatin Cardoso - 22.07.98 - V.U.).

"Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (JTACRESP 42/58).

"A garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade" (RDJTACRIM 11/201).

Importante deixar assentado que a negativa quanto ao direito de apelar em liberdade não está fundada na regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 104.339-SP, mas na existência de pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva, conforme acima registrado e que também foram levados em consideração quando da audiência de custódia, bem em outras decisões deste juízo.

"À luz da nova ordem constitucional, que consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (CF/88, artigo 5º, LVII), a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória é a regra, somente impondo-se o recolhimento provisório do réu à prisão nas hipóteses em que enseja a prisão preventiva, na forma inscrita no artigo 312, do CPP. Na hipótese em que o réu foi considerado reincidente e permaneceu foragido durante todo o curso do processo, não é cabível o benefício de apelar em liberdade. "Habeas corpus" denegado" (STJ - HC nº 7.272 - SP - Rel. Min. Vicente Leal - J. 25.08.98 - DJU 28.09.98).

“Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. A evasão do réu pode ser suficiente para motivar a segregação provisória a fim de garantir a aplicação da lei penal. Precedente. Não se conhece de pedido de extensão da decisão do e. Tribunal a quo, que revogou a prisão cautelar de co-réu, pois o mesmo deveria ter sido dirigido à Autoridade que concedeu a ordem, competente para tanto. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (STJ - RHC nº 12.236 - PR - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 25.03.2002).

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal para CONDENAR o acusado RAFAEL DA SILVA HONÓRIO (R.G. nº 53.170.359) por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente (salário mínimo paulista), na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/06. Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, na forma do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver recolhido.

Expeça-se Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
Juiz de Direito

Roseira, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA